

1511541-82.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511541-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511541-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128853/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 24915898 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2128853 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERLEY CRUZ DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

FERNANDES DEBUA SANTOS DA SILVA e WANDERLEY CRUZ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2022, por volta das 18h, na Av. Luis Gushiken, nº 1300, São Paulo - SP, agindo em concurso, traziam, para fins de tráfico de drogas, 20 porções de maconha, que foram encontradas com Fernandes, e 20 porções de maconha, 22 porções de cocaína e 40 porções de crack, que estavam com Wanderley, tendo como peso líquido total 81,5g de maconha, 20,2g de cocaína e 4,5g de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em 30 de maio de 2022 houve a determinação para a notificação dos réus e apresentação das defesas prévias (fls. 81/83).

O réu Wanderley foi notificado (fls. 166). O réu Fernandes foi notificado e citado na presente data. A defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação, foi apresentada em favor de Wanderley e Fernandes (fls. 118/121). A denúncia foi recebida (fls. 122) e os réus devidamente citados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida os réus interrogados. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação dos réus nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu aumento da pena-base, o reconhecimento da reincidência específica de Wanderley, sem aplicação do redutor e regime fechado para referido réu. Para Fernandes, postulou a incidência da atenuante da menoridade, aplicação do redutor, com regime mais brando.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória para ambos os réus.

Subsidiariamente, argumentou quanto à desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas para Fernandes e para o artigo 37 para Wanderley. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, incidência do redutor, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para Fernandes e direito de recorrer em liberdade para ambos os réus.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando na entrada de uma viela, conhecida por se tratar de ponto de venda de drogas, avistaram os réus juntos. Estavam apenas os dois, que, ao avistarem a presença policial adentraram na viela e empreenderam fuga. Perceberam que um deles estava com blusa de frio, apesar de no dia estar calor e tinha um volume na cintura, e o outro tinha uma bolsa a tiracolo. O policial Francisco desembarcou e foi no encalço deles, não os perdendo de vista até que fossem abordados. O policial Alexsander deu a volta com a viatura para ir na saída da viela. Quando chegou à saída da viela, avistou dois indivíduos, que estavam caminhando. Como não sabia se poderiam ter alguma relação com os outros dois indivíduos vistos, procedeu à abordagem deles, mas nada de ilícito foi encontrado com eles, motivo pelo qual foram liberados. Francisco abordou ambos os réus, acompanhado de outro policial que estava no apoio. Em revista, com Fernandes, no bolso do casaco dele encontraram 20 porções de maconha. Com Wanderley, na bolsa que ele trazia a tiracolo encontraram porções de maconha, crack, cocaína, todas fracionadas, além de alguns papeis com anotações. Não havia dinheiro com quaisquer deles. Ambos disseram que eram apenas usuários. O policial Alexsander recordou-se que Fernandes afirmou que estava apenas vendendo balas no local. Fernandes declarou residir em outro bairro distante. Não se recordavam se Wanderley declarou residir nas proximidades. Não os conheciam anteriormente. Durante a abordagem, ninguém interveio em favor deles. Eles não pareciam estar sob efeito de drogas, segundo Alexsander.

O réu Fernandes, em seu interrogatório, alegou que estava vendendo balas no farol com um amigo de nome Brian, que também foi abordado no dia dos fatos. Viu quando o corréu correu em sua direção, na avenida, sendo seguido por policiais, que abordaram-no e também o interrogando, afirmando que ele teria passado algo ao interrogando. Nega que tenha corrido. Mais um rapaz foi abordado. Não viu onde as drogas foram encontradas e não presenciou a revista ao corréu. Estava com um celular. Não conhecia os policiais militares anteriormente. Viu apenas Wanderley correndo

O réu Wanderley, em seu interrogatório, afirmou que estava na função de "olheiro", negando que tivesse consigo qualquer droga. Afirma que o traficante que vendia as drogas, que conhece por Sidnei, também foi abordado, mas foi liberado. Afirma que o corréu estava vendendo balas na avenida, juntamente com outro indivíduo que também foi abordado e acabou sendo liberado. Não viu se alguma droga foi encontrada com Fernandes.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu Wanderley, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: a variedade, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo que ele foi visto na entrada de uma viela, onde corriqueiramente ocorre o tráfico de drogas e correu ao perceber a presença policial; a incompatibilidade entre a quantidade de droga com a situação financeira declarada pelo réu Wanderley; a ausência de demonstração que as drogas destinavam-se para consumo próprio, tendo em conta a variedade de drogas e a quantidade de porções, além do fato de que não possuía qualquer apetrecho destinado ao uso dos entorpecentes; apreensão de anotações típicas da contabilidade do tráfico, que estavam dentro da bolsa tiracolo que ele carregava. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Observo que as pequenas contradições havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência.

No mais, a versão apresentada pelo réu restou isolada, inexistindo qualquer aspecto a comprovar seus enredos, que sequer se mostra verossímil e apta a infirmar a prática do tráfico de drogas relatada pelos policiais.

Ainda que se argumente sobre o fato de os policiais não terem presenciado a comercialização, irrelevante tal aspecto, haja vista que se trata de crime de conteúdo múltiplo ou variado, sendo que no presente caso traziam as porções das drogas supramencionadas.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 161/162), também a corroborar o contido na denúncia.

No entanto, com relação a Fernandes a situação é diversa, na medida em que, com ele teriam sido encontradas apenas 20 porções de maconha, circunstância insuficiente para se afirmar com absoluta certeza que ele estaria no local praticando tráfico de

drogas. Com ele não foi encontrado dinheiro, anotações ou quaisquer outros objetos que possam estar relacionados com o tráfico. O simples fato de ter corrido também não viabiliza a afirmação de que o destino da droga que estava com ele era a venda, já que é natural que, estando em poder de drogas, fosse correr para evitar sua abordagem, mesmo se tratando de droga destinada a consumo próprio.

Seria o caso de se proceder à desclassificação da conduta de Fernandes, mas para tanto deveria haver aditamento da denúncia pelo Ministério Público, o que não ocorreu nos presentes autos, de forma que o réu deve ser apenas absolvido da imputação da prática de tráfico.

Forçosa, destarte, a condenação dos réus nos termos acima referidos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza excepcionalmente nociva de parte dos entorpecentes encontrados em sua posse (cocaína e crack), em diversas porções destinadas à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo, razão pela qual majoro a pena-base do réu em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, observa-se que Wanderley é reincidente (28ª VC, autos 0065876-53.2017.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 18/03/2022 - fls. 132), motivo pelo qual as penas serão elevadas em 1/6, ficando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente específico.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, trata-se de réu reincidente específico, que demonstrou total insensibilidade com relação à pena a ele aplicada anteriormente, não se justificando outro regime que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, WANDERLEY CRUZ DA SILVA, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

Outrossim, ABOLVO o réu FERNANDES DEBUA SANTOS DA SILVA da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado Wanderley no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a sua reincidência, aspecto que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 122.

Oficie-se para destruição da droga apreendidas.

P.R.I.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA